

0016180-48.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... só, não é suficiente a caracterizar o crime de tráfico. No entanto, o montante e variedade de drogas apreendidas em poder da ré, não deixam dúvidas que serviam para o tráfico de drogas, eis que a quantidade e variedade são incompatíveis com uso.

Tanto é que a testemunha presencial S. M. V. S., declarou em juízo que a ré alugou esse imóvel de mim. Não tinha móvel nenhum, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0016180-48.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0016180-48.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 757/2016 - 44º Distrito Policial - Guaianazes, 8377/2016 - 53º Distrito Policial - Parque do Carmo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDA MARCELO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 789.21

VISTOS.

FERNANDA MARCELO DOS SANTOS, qualificada a fls. 78, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas penas 33, caput, da Lei 11.343/06, porque consta que no dia 26 de novembro de 2016, por volta das 19 h e 17 min, na Rua Padre Luis Gonzaga no 138, Guaianases, nesta cidade e Comarca, tinha em depósito, ocultava e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar: 82 (oitenta e dois) vidros contendo tricloretileno com o volume líquido total de 656 ml (seiscentos e cinquenta e seis mililitros - fls.12 e 55); 491 invólucros contendo tetrahydrocannabinol com o volume líquido de 1.566g (um quilo e quinhentos e sessenta e seis gramas - fs.12 e 54) e o total de 1839 (um mil, oitocentos e trinta e nove) de invólucros diversos contendo cocaína com o peso líquido total de 1.013,5 g (um quilo, treze gramas e cinco decigramas).

A denúncia foi recebida à fl. 122.

Defesa preliminar devidamente apresentada à fl. 158.

Durante a instrução processual, foram ouvidas através do sistema de áudio e vídeo, três testemunhas de acusação, uma de defesa, e a ré foi interrogada.

Em debates, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ré nos exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição da ré pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o crime de uso, aplicação da minorante prevista no §4º do artigo 33, com pena mínima e regime mais brando.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente. A materialidade delitiva veio bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12, dando conta dos 345 porções de cocaína, dos 82 frascos de Lança-Perfume, das 491 porções de maconha, dos 458 eppendorff's de cocaína, dos 159 eppendorff's de cocaína, dos 139 embalagens contendo cocaína, dos 257 eppendorff's de cocaína, dos 481 eppendorff's de cocaína, localizados e apreendidos na residência da ré. Em complementação, o Exame Químico Toxicológico de fls. 56/67, atestou que as substâncias apreendidas eram positivas para cocaína e tetrahidrocannabinol e cloreto de metileno/diclorometano.

A autoria também é incontestada.

As negativas da acusada e os argumentos da Douta Defesa Técnica, não arredaram os fortes indícios e provas diretas que derivaram contra a ré, em especial, pelos laudos periciais, testemunhas inquiridas e declaração da própria acusada, que nada de exculpatório trouxe aos autos.

Na Delegacia de Polícia a ré negou a traficância. Ouvida em Juízo, a ré declarou que eu desconheço os fatos. Eu realmente aluguei a casa, fiz recibo de próprio punho, que eu estava alugando a casa, porque precisava guardar os salgadinhos que eu vendia. Porém não era somente eu que tinha acesso a essa casa. Eu ia lá com menor frequência, até porque meu marido tinha ciúmes, e não gostava que eu conversava com pessoas. Meu marido tinha acesso a casa também, ele ia lá mais do que eu. Ele não deixava eu sair sozinha, hoje não estou mais casada, e passei por um processo difícil e doloroso em razão do relacionamento abusivo que sofri. Cheguei a ser presa no ano de 2019. Eu não falei sobre isso antes, porque não entendia que era um relacionamento abusivo, ele me tratava como rainha.

Em Juízo, a ré reconhece que realmente alugou a casa onde as drogas foram encontradas, porém diz que não tinha conhecimento da existência delas. Relata que seu ex marido frequentava a casa muito mais do que ela, e que não permitia que saísse sozinha ou fosse ao local sem a companhia dele.

No entanto, a versão apresentada pela acusada restou isolada nos autos e em absoluto não convenceu. Tanto é assim que a locação da casa onde estavam as drogas, foi feita pela ré, que assinou o contrato e assinava os recibos.

E mais, como se verá adiante, a locadora do imóvel em Juízo, foi firme em dizer que na ocasião quem frequentava a casa era a ré.

Desta feita, as justificativas da acusada, secundadas por sua defesa, no sentido de que a ré não tinha ciência das drogas não encontraram nenhum respaldo no contexto probatório, eis que todas as provas dos autos apontam em sentido contrário, ou seja, que na ocasião as drogas encontradas, eram sim, de responsabilidade da acusada.

É certo que a quantidade da droga por si só, não é suficiente a caracterizar o crime de tráfico. No entanto, o montante e variedade de drogas apreendidas em poder da ré, não deixam dúvidas que serviam para o tráfico de drogas, eis que a quantidade e variedade são incompatíveis com uso.

Tanto é que a testemunha presencial S. M. V. S., declarou em juízo que a ré alugou esse imóvel de mim. Não tinha móvel nenhum, ela não falou nada. Eu observei que tinha muita lama e alguma coisa estranha. Não tinha cadáver nenhum, tinha era muita droga enterrada. Não tenho condições de reconhecer a ré porque estou com a saúde

debilitada e tudo aconteceu há muito tempo. Tinha muita gente que entrava e saía, homens. Ela me enganou, eu aluguei com tanta boa fé, nunca mexi com drogas antes. Dando respaldo à prova acusatória, referida testemunha confirma que a finalidade da locação da residência por parte da ré, era mesmo tão somente armazenar drogas, tanto que não havia qualquer móvel no interior do imóvel, que o tornasse apropriado para moradia.

Confirmou ainda referida testemunha, a localização das drogas, que haviam sido enterradas em seu quintal pela ré e seus comparsas.

Embora tenha a locadora afirmado que muitos homens também frequentavam a casa, disse que estavam sempre acompanhados da acusada.

Desta feita, a fala da testemunha coloca uma pá de cal na tese defensiva, demonstrando de forma clara e cristalina que na ocasião era ela sim, a responsável pelas drogas, ou ao menos, tinha ciência do armazenamento, e agia em conluio com eventuais terceiros.

Mas não é só. Os policiais militares responsáveis pela prisão da ré, Fernando da Silva Benjamim Gonçalves e Gilson Barbosa Soares, relataram em Juízo de forma firme, segura e em uma só voz que estávamos em patrulhamento de rotina, quando fomos acionados via COPOM, para averiguar localização de drogas. Fomos ao local, em contato com a proprietária do imóvel, ela nos disse que sua inquilina tinha enterrado drogas no quintal. Constatamos a existência das drogas no local, que foram desenterradas, e também no interior da casa alugada pela ré. Não tivemos contato com a ré.

Os policiais militares narraram com segurança e precisão como se deu a localização das drogas relatando todos os detalhes, desde a chegada ao local em razão de denúncia da dona do imóvel, o encontro das drogas, identificação da ré, até final condução de todos ao distrito policial.

Mister se faz, neste momento, dizer que o testemunho dos policiais deve ser valorado como de qualquer outra pessoa, não havendo motivo para de pronto depreciá-lo. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório.

No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ªT., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento."

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Além disso, o depoimento dos policiais foi tranquilo, harmonioso e revelou sincronia lógica. Narraram a situação com firmeza, descrevendo as diligências sem qualquer mácula ou eiva de vício a contaminar a prova. Não houve contradição na parte substancial do que disseram na fase policial e em Juízo e eventuais discrepâncias existentes em seus depoimentos, são normais aos relatos prestados por qualquer ser humano, e em nada abalam a condenação.

Tanto é assim que a jurisprudência afirma: "As pequenas contradições decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas pelas condições em que a prova é realizada. O testemunho demasiado perfeito, esse, sim é que deve gerar desconfiança" (TACRIM-SP-AP- Rel. Nelson da Fonseca - JUTACRIM-SP 67/311).

Tal a circunstância dos autos. A fala das testemunhas mostrou-se coerente, repita-se e firme desde a fase inquisitiva, narrando com clareza o discorrer dos fatos. Em que pesem, pois, os argumentos da defesa, alegando em síntese que tudo não passou de uma armação para incriminar a ré e que os policiais não lograram êxito na prova da traficância, vejo nos autos que todas as circunstâncias apontam em sentido contrário.

Neste contexto, em vista da variedade e quantidade de drogas encontradas em poder da ré, e ainda o relato seguro e firme por parte dos policiais, resta inesoravelmente comprovado que mantinha substância tóxica para consumo e entrega a

terceiros.

Nem se cogite que a ausência de descrição de ato de venda, compra ou qualquer outro que indicasse atividade de mercancia, pudesse vir a inocentar a acusada da imputação descrita na denúncia. E isso porque, tratando-se de tipo penal tido como de conteúdo múltiplo ou variado, preencheu o réu um dos núcleos do tipo denunciado, sendo pois, impossível a absolvição. Para a condenação, na hipótese dos autos, é absolutamente irrelevante não ter o agente, sido surpreendido no ato da venda, bastando que haja indicativos outros, como forma de acondicionamento da droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76 - Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros indicativos de fim de mercancia - Recurso não provido. (Ap. 296.182-3, São Paulo, 4ª C., rel. Canellas de Godoy, 25.04.2000, v.u.).

Destarte, não evidenciou-se qualquer situação que pudesse excluir o crime ou isentar a ré da pena.

Passo a dosar a pena.

Verificando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, atento dolo normal à espécie. Na época dos fatos a ré ainda era primária de sorte que fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na hipótese dos autos, a grande quantidade e variedade de drogas, não autorizariam, em princípio o reconhecimento do redutor. De outro giro, a ré encontra-se solta, compareceu a todos os atos, de maneira que condena-la a uma pena que não comporte o regime aberto, mostra-se demasiado drástico e desnecessário.

Assim, considerando-se a diversidade das drogas, e capacidade lesiva de uma das drogas em questão, tratando-se de cocaína, substância que vem causando estragos de enormes montas nos jovens da sociedade, reduzo a pena base em 1/3, perfazendo 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias multa.

Sobre o tema, já assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que " O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da nova lei de Tóxicos. Na hipótese, à luz do art. 42 da lei 11.343/2006, a natureza da substância entorpecente apreendida - 13 (treze) pedras de crack - justifica a não aplicação do redutor em seu grau máximo, qual seja: 2/3" (5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje 05/06/2012). O valor do dia multa será o mínimo legal.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar FERNANDA MARCELO DOS SANTOS, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº11.343/06, a cumprir, em regime inicial aberto, a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias multa.

Na hipótese específica destes autos, o regime aberto se justifica tendo em vista que a ré era primária, foi solta no curso do processo e comprovou que encontra-se trabalhando, sendo que faze-la retornar aos sistemas carcerários revela medida excessivamente drástica como forma de repressão e retribuição.

De outro giro, não é possível a aplicação de qualquer substituição, porque o escopo do legislador foi beneficiar delitos que não mantêm repercussão na sociedade, o que não é o caso do tráfico de drogas, cujo promovente deve ser segregado do convívio social. Não se pode perder de vista ainda, que o artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos prevê, de forma expressa a vedação da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

É certo que o STF, nos autos do HC 97256/RS, cujo relator foi o Ministro Carlos

Ayres Brito, declarou de forma incidental a inconstitucionalidade da vedação em apreço. Mas é certo também que referida decisão foi proferida por maioria apertada (6x4) e reconhecida, apenas na hipótese específica daqueles autos, alcançando tão somente, as partes que ali figuraram.

No mesmo sentido, foi a recente decisão proferida pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação nº 0090150-57.2012.8.26.0050, cujo teor passo a descrever: "Como bem colocado pelo Ilustre Desembargador Souza Nery: "inviável a aplicação da pena alternativa. Não só pela própria hediondez do crime, que recomenda maior rigor no escarmento, mas também porque a Lei nº 11.343/06 expressamente veda a benesse aos traficantes, nos precisos termos do que dispõe o seu artigo 44, caput. Tal dispositivo legal foi editado pelos poderes competentes, goza de presunção de constitucionalidade e não parece ofender a Constituição de República de modo franco e direto. Não desconheço que foi reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo pelo Excelso Pretório (HC 97.256) no ano de 2010, mas essa decisão foi tomada por maioria apertada (6 x 4) e valeu somente para o processo julgado (incidenter tantum)."

Desta forma, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade erga omnes, de maneira que, em cada caso concreto, a vedação imposta pela Lei de Tóxicos, pode ser aplicada e reconhecida.

Oficie-se à autoridade policial, oportunamente, para incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de junho de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA